



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2017.0000614254

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000173-92.2016.8.26.0574, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante JOÃO CARLOS SCARPELIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em virtude da ausência de apelo por parte do Ministério Público, apenas negaram provimento ao apelo Defensivo interposto em favor de JOÃO CARLOS SCARPELIM. De ofício, contudo, reconheceram a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena aplicada a 03 meses e 15 dias de detenção. Resta mantida, no mais, a r. sentença por seus jurídicos fundamentos. Com lastro na fundamentação lançada, fica, portanto, desde já determinada, após o decurso do prazo para interposição de embargos de declaração, a expedição de mandado de prisão em regime semiaberto, bem como de carta de guia, para que seja iniciado de imediato o cumprimento da pena em definitivo. Tendo havido modificação no julgamento, comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 1º da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe foi dada pela Resolução CNJ n. 237/2016. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO ANTÔNIO COGAN (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SÉRGIO RIBAS.

São Paulo, 17 de agosto de 2017.

GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Apelação nº 0000173-92.2016.8.26.0574

Apelante: João Carlos Scarpelim

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Comarca: Cerqueira César

Voto nº 14117

Ameaça – Violência doméstica – Conjunto probatório suficiente quanto a ter a vítima efetivamente enfrentado fundado receio de sofrer mal injusto e grave – Configuração
Configura o crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, a conduta daquele que venha a infundir na vítima verdadeiro receio de sofrer mal injusto e grave. Na hipótese de existirem elementos seguros nesse sentido, será de rigor a condenação do acusado.

Ameaça – Intimidações sérias e idôneas que infundem fundado temor na vítima – Caracterização

Resta caracterizado o crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, na hipótese de restar evidenciado que as intimidações do acusado, ameaçando a vítima, foram sérias e idôneas, infundindo-lhe verdadeiro receio de vir a sofrer mal injusto e grave.

Ameaça – Violência doméstica – Embriaguez voluntária do agente que não chega a afastar a intimidação à vítima – Presença do elemento subjetivo do tipo reconhecida – Excludente não configurada

A embriaguez não tem o condão de, por si só, afastar o elemento subjetivo do tipo, que consiste na intenção de intimidar, infundir medo, se não se fizerem presentes indícios mínimos de que se cuidava de mera bravata por parte do agente. Sendo ela voluntária, não afasta tampouco, nos termos do art. 28, II, do CP, a imputabilidade penal, pelo que não se cogita da possibilidade de exclusão da culpabilidade do agente.

Lesão Corporal – Violência doméstica ? Conjunto probatório desfavorável ao agente – Exame de corpo de delito associado a declarações coerentes prestadas pela vítima e testemunha – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo

Nos crimes cometidos com violência doméstica, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida, se coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Pena – Substituição da pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa – Descabimento por ser o réu reincidente em crime doloso – Entendimento do art. 44, inc. II, do CP

Em se cuidando de reincidente, não se admite a substituição da pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa, por expressa vedação do art. 44, inc. II, do CP.

Apelação – Mandado de Prisão a ser expedido após acórdão



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

condenatório proferido por órgão de Segundo Grau no qual impôs-se pena privativa de liberdade – Trânsito em Julgado da matéria de fato – Admissibilidade – Interposição eventual de Recursos Especial e Extraordinário desprovida de efeito suspensivo

Eventuais recursos de natureza especial ou extraordinária que venham a ser interpostos, respectivamente para o STJ ou para o STF, não estão abarcados na ideia de duplo grau de jurisdição, mesmo porque vêm eles desprovidos de efeito devolutivo amplo, na medida em que não se prestam ao debate da matéria fático-probatória, tendo seu âmbito de cognição restrito à matéria de direito. Sua previsão não visa, com efeito, a outorgar uma terceira ou quarta oportunidades para que determinado pronunciamento jurisdicional, contra o qual o sucumbente se insurge, seja revisto; sua finalidade precípua é, antes, proporcionar a essas Cortes superiores a possibilidade de verificar se houve, *in concreto*, vulneração à lei federal ou às normas constitucionais, bem como, subsidiariamente, estabilizar, uniformizar e pacificar sua interpretação.

A presunção de inocência não possui – nenhum princípio o tem – caráter absoluto, devendo ser analisada sempre em conjunto com os demais princípios de igual hierarquia que integram o arcabouço Constitucional, tais como aqueles da proporcionalidade e da duração razoável do processo, cabendo ao intérprete valorar cada um deles, sopesando-os, para determinar qual irá prevalecer em cada situação concreta. Em havendo colidência entre princípios, a divergência a ser dirimida será, com efeito, apenas aparente.

Na seara criminal, a coisa julgada se forma de modo fracionado, conforme a ação penal avança. O próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu cuidar-se de instituto de envergadura constitucional, que se consolida em capítulos autônomos, cujo conteúdo vai precluindo, consoante não venha a ser atacado no curso da ação por recurso.

Torna-se, portanto, a parte relativa ao mérito da acusação e às provas “indiscutível, imutável”, tão logo seja realizado o julgamento em segundo grau de jurisdição, de tal sorte a ocorrer exatamente nesse momento o trânsito julgado desse capítulo da decisão, devendo o Juiz, então, expedir mandado de prisão ou recomendar o condenado no estabelecimento em que estiver recolhido, bem como determinar a expedição de carta de guia, para que seja iniciado de imediato o cumprimento da pena.

Vistos,

Pela r. sentença de fls. 156/161, prolatada pelo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

MM. Juiz Artur Pessoa de Melo Moraes, cujo relatório ora se adota, JOÃO CARLOS SCARPELIM foi condenado como incurso no art. 129, § 6º, c.c. o art. 61, II, “e” e “h”, ambos do CP, à pena de 02 meses e 24 dias de detenção, bem como no art. 147, *caput*, c.c. o art. 61, II, “f”, ambos do CP, à reprimenda de 01 mês e 12 dias de detenção.

Reconhecido o concurso material entre os delitos, as sanções foram somadas, perfazendo 04 meses e 06 dias de detenção. Foi fixado o regime inicial semiaberto e deferido ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Inconformado, apelou o réu em busca de sua absolvição, alegando ausência de dolo e fragilidade do conjunto probatório colhido para a condenação. Subsidiariamente, requer o abatimento do tempo de prisão cautelar da pena privativa de liberdade a ele imposta, bem como a substituição da reprimenda corpórea por restritiva de direitos.

Processado e contra-arrazado o recurso, a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.

É o Relatório.

O recurso não merece prosperar.

A condenação do acusado pelos crimes de ameaça e lesão corporal culposa, ambos praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo probante.

Segundo restou comprovado, na data dos fatos, João Carlos, durante uma discussão com Thaís Jaline Ferreira, à época sua companheira, ameaçou agredi-la com tapas, por meio de palavras e gestos, chegando a “levantar a mão” para a vítima.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Ainda durante a discussão, João Carlos, que estava com Safira Vitória Ferreira Scarpelim, filha recém-nascida do casal, no colo, imprudentemente bateu a cabeça do bebê contra o batente de uma porta, causando na criança lesões corporais de natureza leve.

A materialidade do delito de lesão corporal culposa restou perfeitamente demonstrada pelo auto de exame de corpo de delito de fls. 18/19, que atestou ter Safira Vitória sofrido contusão na cabeça, nas regiões temporal e occipital, bem como pelo laudo de lesão corporal de fls. 72, cuja conclusão foi no mesmo sentido.

A prova oral (fls. 141 e mídia digital encaminhada ao gabinete deste Relator) colhida na instrução criminal, que conta com os depoimentos da vítima Thaís Jaline Ferreira, de testemunha presencial, de conselheira tutelar e de Policial Militar, todos nos exatos termos acima narrados, além da integral confissão do réu, mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a realização dos tipos penais e a dinâmica dos fatos, como o dolo do agente com relação à ameaça e sua culpa quanto à lesão corporal, bem como sua vinculação à autoria de ambos os crimes.

Configura o delito de ameaça, previsto no art. 147 do CP, com efeito, a conduta daquele que venha a infundir na vítima verdadeiro receio de sofrer mal injusto e grave. Na hipótese de existirem elementos seguros nesse sentido, tal como ocorreu no presente caso, é mesmo de rigor a condenação do acusado.

Destaque-se ainda que, na hipótese vertente, restou evidenciado que as intimidações do acusado, ameaçando a vítima, foram sérias e idôneas, infundindo-lhe verdadeiro receio de vir a sofrer mal injusto e grave.

Eventual embriaguez do recorrente, outrossim,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

não tem o condão de, por si só, afastar o elemento subjetivo do tipo, que consiste na intenção de intimidar, infundir medo, se não se fizerem presentes indícios mínimos de que se cuidava de mera bravata por parte do agente. Sendo ela voluntária, não afasta tampouco, nos termos do art. 28, II, do CP, a imputabilidade penal, pelo que não se cogita da possibilidade de exclusão da culpabilidade do agente.

É de ressaltar-se, ademais, que, nos crimes cometidos com violência doméstica, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida, se coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, como no caso em tela, assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria, dolo ou culpa.

As reprimendas, conquanto dosadas e fundamentadas em consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, com a imposição do regime inicial semiaberto, comportam reparo, tão somente para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

A) Crime de ameaça:

O Magistrado *a quo* fixou benevolmente a sua pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 mês de detenção. Aludidas circunstâncias não eram, todavia, efetivamente favoráveis ao acusado, cabendo a majoração nesta fase, em virtude da personalidade agressiva do agente, bem como da segunda condenação transitada em julgado, pois que, por ser o acusado reincidente, deveria ter sido computada a título de mau antecedente. Apenas a ausência de apelo por parte do Ministério Público impede a correção.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Em virtude da presença das circunstâncias agravantes previstas no art. 61, II, “f”, bem como da dupla reincidência específica do réu (certidões de fls. 88 e 90), a reprimenda foi elevada de 2/5, resultando em 01 mês e 12 dias de detenção. Deve ser reconhecida, nesta fase, a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual a sanção fica ora reduzida de 1/6, perfazendo 01 mês e 05 dias de detenção.

Inaplicáveis causas de aumento ou de diminuição, a pena resta finalizada em 01 mês e 05 dias de detenção.

B) Lesão corporal culposa:

O Magistrado *a quo* fixou, também aqui, a sua pena-base no mínimo legal de modo benevolente, ou seja, em 02 meses de detenção. A exemplo do que já foi mencionado com relação ao crime de ameaça, aludidas circunstâncias não eram, todavia, efetivamente favoráveis ao acusado, cabendo a majoração nesta fase, em virtude da personalidade agressiva do agente, bem como da segunda condenação transitada em julgado, pois que, por ser o acusado reincidente, deveria ter sido computada a título de mau antecedente. Aqui também, apenas a ausência de apelo por parte do Ministério Público impede a correção.

Em virtude da presença das circunstâncias agravantes previstas no art. 61, II, “e” e “h”, bem como da dupla reincidência do réu (certidões de fls. 88 e 90), a reprimenda foi elevada de 2/5, resultando em 02 meses e 24 dias de detenção. Deve ser reconhecida, nesta fase, a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual a sanção fica reduzida de 1/6, perfazendo 02 meses e 10 dias de detenção.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Inaplicáveis causas de aumento ou de diminuição, a pena resta finalizada em 02 meses e 10 dias de detenção.

C) Do concurso de crimes:

Reconhecido o concurso material entre os delitos, correta a soma das reprimendas, resultando, após as alterações acima efetuadas, no total final de 03 meses e 15 dias de detenção.

Adequada, por fim, diante da dupla reincidência ostentada pelo acusado, a fixação do regime inicial semiaberto.

Em se cuidando de reincidente, não se admite, ademais, a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa, por expressa vedação do art. 44, inc. II, do CP. Descabe, ainda, a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, I, do CP.

Conquanto a detração do tempo de prisão provisória seja matéria mais afeta à Vara das Execuções Criminais, conforme expressa disposição contida no art. 66, III, "c", da LEP, é forçoso reconhecer não ser o *quantum* imposto de privação de liberdade o único fator que deve ser considerado para a fixação de regime inicial para seu cumprimento.

O art. 387, § 2º, do CPP, incluído a partir de 2012, efetivamente prevê que o tempo de prisão provisória deva ser computado para fins de determinação do regime inicial. Em momento algum, contudo, o legislador observou que apenas o *quantum* de pena imposto, já descontado o tempo de prisão cumprida, fosse utilizado como parâmetro único para escolha do regime de cumprimento de pena seria. O legislador de 2012, ao incluir mencionado parágrafo ao art. 387 do CPP, não revogou, com efeito, a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

regra prevista no art. 59, III, CP, consoante o qual o Juiz levará em conta as condições judiciais constantes do *caput* daquele dispositivo não apenas para fixar a pena-base, como também para estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Não se pode perder de vista que, no caso concreto, o fato de que se cuida de reincidente específico, além do que as circunstâncias judiciais eram desfavoráveis, embora o Juiz não as tenha considerado para majorar a pena-base.

Cumprido, por fim, observar que tem prevalecido o entendimento no sentido de formar-se a coisa julgada criminal de modo fracionado, em capítulos autônomos, cujo conteúdo vai precluindo, consoante a ação penal avança, e não seja atacado no curso da ação por recurso, quer por opção ou falha da parte sucumbente, quer por absoluta vedação legal.¹

Na medida em que a parte relativa ao mérito da acusação e às provas se torna “indiscutível, imutável”, a partir da realização do julgamento em segundo grau de jurisdição, é forçoso reconhecer que a imediata expedição de carta de guia para o cumprimento da pena, nos termos do art. 674 do CPP, não implicará em descumprimento ao quanto previsto no art. 283 do CPP, dada a ocorrência do trânsito julgado ao menos desse capítulo da decisão.

Ante o exposto, em virtude da ausência de apelo

¹ **Constitucional – Habeas Corpus – Princípio Constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) – Sentença penal condenatória confirmada por Tribunal de Segundo Grau de Jurisdição – Execução Provisória – Possibilidade** 1. A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo art. 5º, inciso LVII da Constituição Federal. 2. *Habeas corpus* denegado (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 126.292/SP. Impetrante: Maria Claudia de Seixas. Paciente: Marcio Rodrigues Dantas. Coator: Relator do HC nº 313.021 do Superior Tribunal de Justiça. Relator: Ministro Teori Zavascki. Tribunal Pleno. Maioria de votos. Brasília, 17 de fevereiro de 2016. Ata nº 71/2016. **Diário da Justiça Eletrônico n. 100**. 17 Maio 2016. Disponível em: <<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=309493860&tipoApp=.pdf>>. Acesso em: 24 Ago. 2016.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

por parte do Ministério Público, apenas se nega provimento ao apelo Defensivo interposto em favor de JOÃO CARLOS SCARPELIM. De ofício, contudo, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena aplicada a 03 meses e 15 dias de detenção. Resta mantida, no mais, a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.

Com lastro na fundamentação lançada, fica, portanto, desde já determinada, após o decurso do prazo para interposição de embargos de declaração, a expedição de mandado de prisão em regime semiaberto, bem como de carta de guia, para que seja iniciado de imediato o cumprimento da pena em definitivo.

Tendo havido modificação no julgamento, comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 1º da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe foi dada pela Resolução CNJ n. 237/2016.

ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR